

0001479-95.2016.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBER JUNIOR DA SILVA SILVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual CLEBER JUNIOR DA SILVA SILVEIRA, maior de 18 e menor de 21 anos na data do fato, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0001479-95.2016.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001479-95.2016.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBER JUNIOR DA SILVA SILVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual CLEBER JUNIOR DA SILVA SILVEIRA, maior de 18 e menor de 21 anos na data do fato, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia (fls. 01/02) que, no dia 03 de setembro de 2016, em torno da 02h24min, na Rua Agostinho Navarro, na via pública, altura do nº 971, Conceição, nesta cidade e Comarca de Osasco, CLEBER JUNIOR DA SILVA SILVEIRA, maior de 18 e menor de 21 anos, qualificado a fl. 08, trazia consigo drogas, sem autorização e em

desacordo com a determinação legal e regulamentar, para consumo de terceiros, consistentes em 17 (dezessete) invólucros plásticos, do tipo "eppendorf", contendo cocaína, no total de 12,52g (doze gramas e cinquenta e dois centigramas) e 05 (cinco) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L (maconha), no total de 07,19g (sete gramas e dezenove centigramas), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 11 e 16, laudo de constatação de fls. 18 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado.

Narra, ainda, a inicial acusatória que, segundo se apurou, policiais militares em patrulhamento pelo sítio dos fatos, avistaram o denunciado parado em plena via pública, no meio da madrugada, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Considerando a atitude suspeita, os milicianos abordaram-no. Em revista pessoal, os policiais lograram encontrar, no bolso da blusa do denunciado, os entorpecentes apreendidos, e, no bolso traseiro de sua calça, a quantia de R\$ 190,00 (cento e noventa reais), em dinheiro, em notas trocadas, fruto da mercancia espúria de drogas. Questionado, o denunciado confessou, informalmente, aos policiais, que ali realizava o comércio de substância ilícitas. Pela forma de acondicionamento das drogas, pela quantidade e variedade de entorpecentes e pelas demais circunstâncias do fato criminoso, dentre as quais a confissão informal e a presença de numerário de origem desconhecida, demonstrou-se que as drogas se destinavam à venda para consumo de terceiros.

Auto de prisão em flagrante às fls. 03.

Auto de exibição e apreensão às fls. 12 e 17. Fotografias dos objetos apreendidos às fls. 24/26.

Laudo pericial toxicológico de constatação às fls. 19. Laudo pericial toxicológico definitivo às fls. 180/182.

Folha de antecedentes às fls. 202/204.

Foi concedida ao acusado liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em sede de plantão judiciário (fls. 45/48). Alvará de soltura expedido às fls. 50/53 e cumprido às fls. 69/70.

Notificado às fls. 100/103, o acusado apresentou defesa preliminar por intermédio da Defensoria Pública às fls. 94/99.

A denúncia então, foi recebida às fls. 104, no dia 28 de junho de 2017, ocasião em que também foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

O E. TJSP, em um primeiro momento, caçou o benefício de liberdade provisória do acusado e decretou sua prisão preventiva, determinando imediata expedição do mandado de prisão em seu desfavor (fls. 111/113).

Não obstante, às fls. 106/108, sobreveio comunicação da concessão de liminar em habeas corpus pelo C. STJ, determinando a soltura do acusado, o que foi confirmado pelo v. acórdão de fls. 126/132. Alvará de soltura cumprido às fls. 120/122.

A audiência de instrução foi realizada às fls. 168/172, tendo sido ouvidas as testemunhas Lining Silva de Oliveira e Erick Santos Souza. Na mesma oportunidade, foi também realizado o interrogatório do acusado CLEBER JUNIOR DA SILVA SILVEIRA.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais em audiência, às fls. 172. Requereu a condenação nos termos da inicial acusatória. Aduziu que, na primeira fase da dosimetria das penas, as reprimendas devem ser aumentadas em 1/3, já que há alto grau de culpabilidade do acusado, já que ele comercializava dois tipos de drogas por ocasião do flagrante, além de ter R\$ 190,00 (cento e noventa reais) em

dinheiro, indicando que já havia vendido boa parte de entorpecentes; além disso, possui conduta social desajustada e voltada para o meio criminoso, por ser encontrado traficando novamente após os fatos em apuração. Na segunda fase dosimétrica, requereu o reconhecimento de duas atenuantes, eis que o réu confessou espontaneamente a prática delitiva, além de ser menor de 21 anos na data dos fatos. Na terceira fase da dosimetria, por fim, sustentou inexistir causa de aumento ou de diminuição incidente, notadamente por estar o réu envolvido com o crime organizado, desempenhando papel de vendedor em subordinação a uma cadeia de tarefas. Pugnou pela fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, em razão da grande quantidade de entorpecentes vendidos e da reiteração delitiva após a prisão em flagrante por este feito.

Por sua vez, em memoriais escritos (fls. 176/179), a Defesa consignou que diante dos elementos de prova produzidos em juízo, em especial, pela confissão do acusado com relação a denúncia, a Defensoria Pública deixa de se manifestar pela sua absolvição, passando a debater sobre a dosimetria da pena. Outrossim, requereu a fixação da pena-base no patamar mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase dosimétrica; a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas na terceira fase da dosimetria; a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, tendo em vista a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº. 8.072/90, com redação dada pela Lei 11.464/07, bem como o teor da Súmula 718 do STF; no mais, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É relatório.

Fundamento e decido.

I - Em que pese o princípio da identidade física do juiz previsto no art. 399, §2º do Código de Processo Penal, anoto que o juiz que findou a instrução se removeu da 4ª Vara Criminal de Osasco. Sendo assim, mesmo não tendo colhido a prova, passo a proferir sentença valorando objetivamente e segundo os marcos legais, a prova produzida.

II - Quanto ao mérito:

O pedido é improcedente

Consto que a análise das premissas fáticas expostas na inicial pelo Ministério Público para justificar a pretensão de condenação serão consideradas tanto sob a ótica do tipo penal, quanto das provas orais valoradas em contraditório judicial. Em outras palavras, buscar-se-á uma reconstrução fático-probatória que se aproxime da verdade e que vá além de qualquer dúvida razoável e possa justificar, ao final, a imposição de pena.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória não é suficiente a justificar a responsabilidade penal da ré. Não logrou o Ministério Público superar a presunção constitucional para além de qualquer dúvida objetivamente razoável, conforme passo a expor.

Em que pese a materialidade esteja demonstrada nos autos por meio do laudo pericial (fls. 180/182), a imputação da autoria não está suficientemente demonstrada nos autos.

Com efeito, a finalidade epistêmica do processo penal é a busca da verdade, ainda que de forma aproximada, por meio de reconstrução fática que leve a superação do postulado da presunção de inocência. Entretanto, este objetivo teleológico deve ser buscado com respeito as regras legais e constitucionais de produção e valoração das provas. Nesse sentido: “assim, no Brasil, os códigos processuais, civil e penal,

dispõem justamente acerca da validade da prova da verdade, que deverá seguir um trâmite que não cause surpresa às partes (livre acesso), que amplie sua participação no discurso relacionado ao seu enunciado (contraditório), que seja adequada e idônea ao fato que se quer provar e que não seja obtida por meios ilícitos. A busca da verdade não é, assim, orientada para a obtenção da verdade substancial, mas apenas da verdade provavelmente admitida. Não vigora mais, assim, no processo a busca da verdade real. Até porque, como já se disse, não existe essa suposta verdade real. Seria uma pretensão audaciosa do direito entender que o juízo possa fazê-lo unicamente pelos instrumentos legais.” (TAVARES, Juarez, CASARA, Rubens. Prova e verdade. 1ª ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020, p. 147).

Cumprir pontuar, nesse prisma, que o Código de Processo Penal adotou o sistema do livre convencimento objetivo motivado do juiz, pelo qual incumbe ao magistrado formar sua convicção a partir da livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, desde que fundamentadamente e observando as regras legais.

Uma das regras legais de valoração racional da prova vem insculpida no art. 155 do CPP. Este comando legal, a seu turno, estabelece limites ao livre convencimento objetivo do juiz, na medida em que dispõe que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em outras palavras, não é lícito ao julgador formar sua convicção e, por conseguinte, proferir sentença condenatória com base em elementos indiciários, colhidos em sede inquisitorial. É preciso que, quanto às provas orais, sejam elas avaliadas em contraditório judicial, com a observância da sistemática processual.

No caso em tela, não é possível a este Magistrado, o qual, repita-se, não colheu a prova, a valoração da prova oral produzida eis que inviável qualquer reconstrução histórico-fática.

É de rigor anotar que as provas produzidas em juízo (oitiva de dois policiais militares) não trazem uma segurança cognitiva, objetivo-valorativa, para eventual decreto de condenação e isto porque se percebe que a produção da prova foi toda ela orientada e coordenada pelo Magistrado, o qual, de fato, fora o protagonista da fase instrutória.

Verifico que as informações, logo as respostas na sequência, foram introduzidas no depoimento dos policiais pelo Magistrado para que estes pudessem confirmar o contido no auto de prisão em flagrante.

E tanto o Magistrado fora o protagonista da instrução probatória que não houve qualquer repergunta pela acusação. Vale dizer, o próprio Magistrado esgotou o conteúdo informacional das testemunhas. Assim, não sendo observada, minimamente, a ritualística do art. 212 do CPP e, ainda, vergastado o devido processo legal na dimensão da necessidade da observância do processo acusatório, faltam garantias epistêmicas mínimas para a valoração racional objetiva por parte deste Juízo, o qual, repita-se mais uma vez, não colheu os depoimentos e apenas neste ato profere sentença devido a remoção do antigo Magistrado.

Ao invés do Magistrado, sublinhe-se, permitir um relato livre das testemunhas e, posteriormente, arguição pelas partes, complementando ao final, se necessário, buscou confirmar – como forma de chancela – o auto de prisão em flagrante.

Nesse sentido: Nesse sentido: STF – HC n. 187.035/SP – Rel. Min. Marco Aurélio – 1ª T – j. 06.04.2021). Ou ainda: Audiência de instrução e julgamento. Inquirição diretamente pelo magistrado. Protagonismo judicial e abstenção do Ministério Público. Irregularidade. Questão de ordem suscitada na audiência pela defesa.

Prejuízo evidenciado. Art. 212 do CPP. Violação. Nulidade dos atos processuais. (HC 735.519/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 6ªT., j. 16.08.2022. Também: STJ – HC nº 726749 - SP – Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – j. 06.05.2022; AgRg no HC n. 721.949/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 8.03.2022.

Assim, desconsiderando a fase probatória judicial, não é possível qualquer juízo de mérito exclusivamente diante dos elementos trazidos no inquérito policial, ainda mais porque não se trata de prova irrepetível.

No caso dos autos, as provas são eminentemente orais e não houve a produção de prova – sujeita ao crivo do contraditório – que permita a demonstração, para além de qualquer dúvida racional-objetiva, das premissas fáticas da acusação previstas na denúncia. Os policiais, em suma, apenas confirmaram as informações trazidas pelo Magistrado e previstas no auto de prisão em flagrante.

Além do mais, há dúvidas sobre o motivo da abordagem do acusado ou, em outras palavras, quais as fundadas razões que motivaram a busca pessoal eis que, segundo a inicial, a abordagem teria ocorrido porque o acusado estava parado na via pública. Os policiais, por sua vez, pelo que se compreende do depoimento conduzido pelo magistrado, afirmaram tratar-se de abordagem de rotina.

Destarte, tendo como base uma colheita de prova baseada em ato inquisitivo do magistrado, somando a ausência de certeza de legalidade quanto a prova, não é possível a formação de qualquer juízo cognitivo de condenação baseado em preceitos democráticos de respeito aos cânones legais-constitucionais

Nesse diapasão, sendo a confissão o único elemento de prova, eis que desconsiderada a instrução processual conduzida por outro magistrado, impossível a procedência de mérito, consoante dicção do art. 197 do CPP.

O direito penal, frise-se, não se contenta com conjecturas, nem mesmo com probabilidade de autoria. A moderna dogmática penal e processual penal exige a convicção plena do julgador, base ética indeclinável amparada em substrato material valorativo produzido em contraditório. Em outras palavras, a dúvida, por menor que seja, milita sempre em favor do acusado, eis que a presunção de inocência é corolário de um Estado de direito democrático.

Diante do exposto, com fundamento no art. 386, inc. VII do CPP, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente ação penal e ABSOLVO CLEBER JUNIOR DA SILVA SILVEIRA, da acusação de ter infringido o art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Determino a destruição das drogas apreendidas. Oficie-se.

Após, arquivem-se.

P.R.I.C.

Osasco, 08 de setembro de 2022.